

FAZLINA BINTI MUSTAFA

lwn

MUHAMMAD AKHBAR BIN HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 19 Julai 2024 / 13 Muharram 1446H]

Kes Rayuan No.10000-028-0092-2022

[Rayuan Terhadap Perintah Hak Jagaan Anak Dibawah Seksyen 82,85 dan 88 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Zulsyahmi bin Kamarulzaman
(Tetuan Mu'az Aiman Halem Auzan & Associates)*

*Puan Nurbaini binti Mohamed Amin
(Tetuan Yusof Zain & Associates)*

Peguam Syarie Responden : *Puan Siti Aishah binti Din
Puan Nur Azathul Hashima binti Md Yaseen
(Tetuan Aishah Din & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

Pendahuluan

- [1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu/Defendan melalui Notis Rayuan bertarikh 3/10/2022 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) pada 20/9/2022 dalam kes Saman No.10207-028-0779-2020.

[2] Pada tarikh tersebut YA Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah sebagaimana terma-terma berikut:

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff dan memerintahkan hak jagaan anak bernama Nur Amira Farzana binti Muhammad Akhbar (No. Mykid: 130214-06-0216) diserahkan jagaan kepada Plaintiff dan Defendan bersama dan penentuan berdasarkan persetujuan dan kemahuan anak tersebut pada bila-bila masa yang dipersetujui.*
- iii. *Mahkamah memerintahkan hak jagaan kekal anak ke-2 bernama Nur Amira Fathiah binti Muhammad Akhbar (No. MyKid: 170805-06-0054) diserahkan kepada Plaintiff (bapa).*
- iv. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan, bermalam dan membawa keluar anak tersebut kepada Defendan pada waktu cuti persekolahan dan diberikan setiap hari Sabtu hingga Ahad setiap minggu dan pada hari-hari lain berdasarkan persetujuan pihak Plaintiff.*
- v. *Mahkamah memerintahkan hak bagi kedua-dua anak bermalam pada Hari Raya Aidilfitri dibahagikan secara bergilir kesemua anak mengikut tahun dengan pembahagian 3 malam bagi perayaan Aidilfitri dan 2 malam bagi perayaan Aidiladha dan penentuan tersebut dimulai dengan pihak Defendan bermula perayaan pada tahun 1444H.*
- vi. *Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia atau pihak Jabatan Imigresen Malaysia hendaklah memastikan Perintah ini dapat dilaksanakan*

dengan baik jika pihak-pihak dalam kes ini memerlukan bantuan proses pelaksanaan Perintah ini.

Fakta Kes

[3] Pihak-pihak telah berkahwin pada 26/5/2012 di Rompin, Pahang dan bercerai pada 4/7/2018 di Mahkamah Rendah Syariah Rompin. Sepanjang perkahwinan, Perayu dan Responden dikurniakan dua orang anak perempuan iaitu:

- i. Nur Amira Farzana binti Muhammad Akhbar (No. Mykid: 130214-06-0216) (*selepas ini dirujuk sebagai “anak pertama”*)
- ii. Nur Amira Fathiah binti Muhammad Akhbar (No. MyKid: 170805-06-0054) (*selepas ini dirujuk sebagai “anak kedua”*)

Selepas bercerai, kedua-dua anak ini berada di bawah jagaan Perayu.

[4] Pada 16/10/2020 Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan bagi kedua-dua anak tersebut dengan alasan mempunyai kedudukan kewangan yang stabil dan tidak pernah gagal memberikan nafkah anak. Responden juga mendakwa Perayu tidak layak mendapat hak jagaan disebabkan kegagalan Perayu memberi kerjasama untuk Responden berjumpa dengan anak-anak dan status Perayu yang telah berkahwin lain.

[5] Pada 20/9/2022 YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas tanpa kehadiran Perayu. Perayu

mendakwa tidak pernah menerima sebarang notis untuk hadir pada prosiding bertarikh 20/9/2022 dan hanya mengetahui perintah tersebut pada 22/9/2022 melalui instagram isteri Responden. Tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan dan perjalanan prosiding kes tersebut, maka Perayu memfailkan rayuan ini.

Alasan Rayuan

[6] Perayu memplidkan sepuluh (10) Alasan Rayuan sebagaimana yang terkandung pada halaman 50-52 Rekod Rayuan. Alasan-Alasan tersebut secara ringkasnya dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang dan hukum Syarak apabila memberikan hak jagaan anak pertama secara bersama dan anak kedua kepada Responden tanpa mengambil kira keseluruhan fakta kes, kebajikan dan status anak kedua yang masih belum mumaiyiz (**Alasan Rayuan Pertama, Kedua dan Ketiga, Kesembilan dan Kesepuluh**).
- ii. YA Hakim Bicara telah terkhilaf daripada segi undang-undang dan fakta apabila mendengar dan memutuskan kes tanpa mengambil kira bahawa prosiding-prosiding tersebut telah dijalankan tanpa kehadiran Perayu. (**Alasan Rayuan Keempat, Kelima, Keenam, Ketujuh dan Kelapan**).

Sungguhpun begitu, hujahan kedua-dua pihak hanya tertumpu kepada isu yang kedua di atas sahaja.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

- [7] Kami tidak berhasrat untuk mengulas satu persatu Alasan Rayuan yang dikemukakan tetapi hanya memfokuskan kepada Alasan Rayuan yang diujahkan sahaja. Bagi maksud tersebut, kami mendapati hanya satu isu utama sahaja yang berbangkit untuk diulas dan diputuskan iaitu **sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mendengar dan memutuskan kes tanpa kehadiran Perayu.**
- [8] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya menyatakan bahawa Mahkamah telah memberi ruang dan peluang yang mencukupi kepada Perayu untuk mengemukakan keterangan. Namun begitu, Perayu gagal berbuat demikian apabila tidak memfailkan apa-apa pembelaan dan gagal hadir untuk memberikan keterangan tanpa sebarang makluman. Atas alasan ini, YA Hakim Bicara berpandangan Mahkamah wajar membuat keputusan berdasarkan keterangan yang ada sahaja.
- [9] Dengan merujuk kepada beberapa kes seperti **Noraini Hanipah lwn. Nasruddin Shah Bhagjit Abdullah [2006] 1 MSLR 66** dan **Maryam Abdullah lwn. Hithir Rashid [2004] 1 MSLR 141** Perayu berhujah YA Hakim Bicara terkhilaf apabila membuat dapatan sedemikian. Menurut Perayu, sungguhpun seksyen 121(1)(b) membenarkan kes diputuskan tanpa kehadiran pihak Defendan, namun ia sepatutnya digunapakai setelah segala usaha bagi memastikan kehadiran pihak-pihak telah dipenuhi. Selain itu, kegagalan Mahkamah Bicara untuk melampirkan waran tangkap, notis makluman perbicaraan dan affidavit penyampaian dalam Rekod Rayuan menunjukkan secara jelas bahawa dokumen-dokumen tersebut tidak wujud

sama sekali dan dengan itu telah memprejudiskan Perayu untuk hadir memberikan keterangan.

- [10] Responden pula dalam hujahan balasnya menyatakan kegagalan Mahkamah untuk melampirkan dokumen-dokumen tersebut adalah tidak relevan untuk dihujahkan. Hal ini kerana Perayu sendiri yang tidak memberikan kerjasama untuk hadir dan memfailkan pembelaan walaupun penyampaian saman dan pernyataan tuntutan telah sempurna. Dengan merujuk kepada kes **Sariah Hassan lwn. Mat Rozi Hamat [2016] MSLR 4** dan **Radzi Abdullah lwn Nursyaireen Radzi & Anor [2013] 1 CLJ (Sya)**, Responden menghujahkan tindakan YA Hakim bicara menggunapakai seksyen 121(1)(b) adalah tepat.
- [11] Penelitian kami kepada Rekod Rayuan dan hujahan-hujahan ini mendapati Perayu hanya tidak berpuas hati berkenaan prosiding bertarikh 20/9/2022 sahaja yang telah dijalankan tanpa pengetahuannya dan bukan berkaitan isu penyampaian saman sebagaimana yang dihujahkan oleh Responden. Hal ini dapat dilihat melalui aduan yang dikemukakan oleh Perayu kepada pihak Mahkamah Bicara melalui Borang Aduan bertarikh 22/9/2022. Pihak Pendaftar Mahkamah kemudiannya telah memberikan penjelasan melalui surat bertarikh 18/10/2022 bahawa notis pemakluman tarikh tangguhan telah dihantar kepada Perayu secara pos berdaftar.
- [12] Bagi menentukan kewajaran tindakan YA Hakim Bicara, kami telah meneliti keseluruhan rekod prosiding dan mendapati secara kronologinya sebagaimana berikut:

Tarikh	Status Prosiding
16/10/2020	Responden memfailkan tuntutan
15/2/2021	Kedua-dua pihak hadir. Mahkamah arahkan Perayu memfailkan pembelaan dan Responden memfailkan penyata keterangan berserta ikatan dokumen.
12/4/2021	Perayu tidak hadir dan Responden hadir. Mahkamah tangguhkan kes untuk bicara.
24/11/2021	Pihak-pihak tidak hadir. Mahkamah tangguhkan kes untuk bicara.
14/3/2022	Pihak-pihak hadir. Responden mengemukakan keterangan dan Perayu menyoal balas. Kes ditangguhkan untuk menyambung keterangan pihak-pihak.
9/8/2022	Perayu tidak hadir manakala Responden hadir. Mahkamah menutup kes dan menetapkan tarikh keputusan.
20/9/2022	Mahkamah memberikan keputusan tanpa kehadiran Perayu.

[13] Kronologi ini menunjukkan bahawa Perayu tidak hadir pada 9/8/2022 untuk menyambung keterangan. Tiada sebarang alasan ketidakhadiran Perayu dicatatkan pada prosiding tersebut. Oleh sebab itu, YA Hakim Bicara telah menutup kes dan menetapkan 20/9/2022 untuk keputusan. Namun, fakta juga menunjukkan Perayu telah hadir semasa sebutan kes pada 15/2/2021 dan 14/3/2022 untuk perbicaraan dimana Perayu telah membuat pemeriksaan balas terhadap Responden.

[14] Berdasarkan rekod kehadiran Perayu ini, kami berpandangan tindakan YA Hakim Bicara menutup kes pada 9/8/2022 agak tergesa-gesa dan kurang cermat. Adalah lebih adil sekiranya Mahkamah Bicara dapat menggunakan budi bicaranya untuk menangguhkan kes bagi memberi peluang sekali lagi kepada Perayu untuk hadir memberi keterangan pada tarikh berikutnya. Keperluan ini selari dengan kehendak seksyen 121(4) yang memperuntukkan:

(4) Mahkamah boleh mengikut budi bicaranya dalam mana-mana hal yang dinyatakan dalam subseksyen (1) atau (3) memerintahkan penangguhan.

[15] Dapatan ini diperkukuhkan lagi dengan ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang dalam kes **Nurfarhani Uma Abdullah lwn. Muhammad Noor Manoranjan Abdullah [2007] 1 MSLR** yang antara lain menegaskan:

*“[40] Sehubungan itu, berdasarkan s 121(4) Enakmen tersebut, Mahkamah Rayuan berpendapat s 121(4) tersebut memperuntukkan kepada budibicara mahkamah bicara dalam meneruskan prosiding di bawah s 121(1)(b). Ini adalah jelas kerana, **suatu perintah penangguhan adalah bagi memastikan hujah kedua belah pihak dapat didengar agar suatu keadilan dapat dicapai.**”*

- [16] Berkenaan dengan dakwaan Perayu yang tidak mengetahui tarikh prosiding 20/9/2022 pula, kami telah meneliti keseluruhan Rekod Rayuan. Namun begitu kami tidak menemui sebarang notis yang dikatakan telah dihantar oleh pihak Mahkamah Bicara kepada Perayu secara pos berdaftar. Situasi ini telah menimbulkan keraguan tentang kewujudan dan status penyerahan notis tersebut kepada Perayu yang sekali gus menjadikan dakwaannya berasas. Pada hemat kami, kegagalan memaklumkan tarikh penangguhan ini telah memprejudiskan hak Perayu untuk hadir pada prosiding 20/9/2022.
- [17] Berhubung dengan keperluan pemakluman melalui notis ini, sukacita untuk kami memetik ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes **Noraini Hanipah lwn. Nasruddin Shah Bhagjit [supra]** yang antara lain menyatakan:
- “[89]YA Hakim Bicara sepatutnya memastikan dan berpuas hati serta mencatatkan di dalam nota keterangan bahawa pihak defendan/perayu memaklumi akan tarikh keputusan tersebut ataupun memastikan satu notis bagi tarikh pendengaran kes telah disampaikan kepada semua pihak dan jika sebaliknya mahkamah hendaklah menangguhkan tarikh pendengaran pada satu tarikh yang lain.”*
- [18] Sungguhpun seksyen 121(1)(b) memberi ruang kepada Mahkamah untuk membuat keputusan tanpa kehadiran Defendan, namun pada hemat kami pemakaiannya adalah tertakluk kepada dua elemen penting iaitu pertama budibicara Mahkamah bagi menjamin keadilan dapat dicapai dan kedua setelah segala proses bagi memastikan kehadiran pihak-pihak telah dipenuhi. Dengan hormatnya kami sekali lagi merujuk dan bersetuju dengan ulasan Panel Rayuan Syariah dalam kes **Noraini Hanipah [supra]** yang menyatakan:

“[25] Sehubungan dengan itu pihak kami berpendapat hujah perayu berhubung dengan pemakaian s 121(1)(b) Akta Tatacara Mal Mahkamah Syariah oleh hakim bicara adalah betul, kerana peruntukan tersebut haruslah dibaca bersama dengan sub-section 4 iaitu melibatkan budibicara mahkamah dalam menjamin keadilan dapat dicapai. Kami dengan hormatnya berpendapat bahawa hakim bicara telah terkhilaf dalam menerimapakai s 121(1)(b) dimana kami berpendapat bahawa seksyen ini hanya boleh digunapakai bila mana segala prosiding bagi memastikan kehadiran pihak-pihak berkaitan dipenuhi.”

Dalam konteks kes ini, kami berpuas hati bahawa proses untuk memastikan kehadiran Perayu tidak dipenuhi apabila tiada pemakluman berkenaan prosiding bertarikh 20/9/2022.

- [19] Dari sudut prinsip keadilan pula, kami berpendapat Perayu masih wajar diberikan peluang untuk mengemukakan keterangan terutamanya berkaitan dengan kelayakan menjaga anak kedua yang masih belum mumaiyiz. Begitu juga dengan anak pertama yang telah mencapai umur mumaiyiz yang mempunyai hak di sisi undang-undang untuk dipanggil menyatakan pilihannya. Pada hemat kami, dengan hanya bergantung kepada keterangan Responden semata-mata, persoalan-persoalan berkaitan kelayakan dan kebajikan anak-anak tersebut masih belum terjawab sepenuhnya.
- [20] Justeru, kami berpandangan dapatan YA Hakim Bicara sebagaimana pada perenggan 22 Alasan Penghakiman (Rekod Rayuan muka surat 42) bahawa anak pertama tidak perlu dipanggil untuk ditemu bual disebabkan kesukaran pihak-pihak memberikan kerjasama adalah suatu andaian dan bersifat pramatang apabila tiada sebarang perintah untuk memaksa kehadiran Perayu dan anak tersebut dikeluarkan terlebih dahulu.

- [21] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada keperluan untuk YA Hakim Bicara memanfaatkan peruntukan undang-undang sedia ada bagi mendapatkan keterangan daripada kedua-dua belah pihak sebelum membuat apa-apa keputusan. Kegagalan berbuat demikian hanya akan menghalang keadilan semulajadi (*natural justice*) kepada pihak yang dinafikan haknya. Hal ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW ketika mengutuskan Saidina Ali menjawat jawatan Qadi ke Yaman dimana Rasulullah SAW telah bersabda:

فإذا جلس بين يدك الخصمان فلا تقضين، حتى تسمع من الآخر، كما
سمعت من الأول

“Apabila datang dua orang yang bertelingkah duduk di hadapan kamu, jangan sekali-kali kamu menghukum sehingga kamu mendengar hujah pihak yang kedua sepertimana yang pertama.”

Kesimpulan

- [22] Sungguhpun seksyen 121(1)(b) membenarkan kes diputuskan tanpa kehadiran Perayu, namun ia harus dilihat secara menyeluruh dan tertakluk kepada sejauh mana keadilan dapat dicapai. Bagi maksud rayuan ini, kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan kes tanpa kehadiran Perayu. Bagi memperbetulkan kekhilafan ini, Perayu wajar diberi peluang untuk membereskan keterangannya sebelum apa-apa keputusan dibuat.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITERIMA**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 20/09/2022 dalam kes Saman No. 10207-028-0779-2020 **DIBATALKAN**.
3. Prosiding kes Saman No. 10207-028-0779-2020 hendaklah diteruskan dengan keterangan Perayu sehingga selesai.

Penghakiman ini dibaca dan ditandatangani oleh;

.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor